Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Estrela

Rua XV de Novembro, 5 - Bairro: Centro - CEP: 95880000 - Fone: (51)3098-5398 - Balcão Virtual: (51) 99515-5879 - Email: frestrela2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006706-05.2023.8.21.0047/RS

AUTOR: LUANA PAOLA BELLO GREGORY

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

Vistos, etc.

LUANA PAOLA BELLO GREGORY ajuizou *ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e materiais* contra a **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA**. Relatou que teria sido diagnosticada com alteração no polimorfismo do GEN PAI I 4G5G e do GEN ECA ID, resultando em Trombofilia Hereditária, patologia que aumenta a predisposição de formação de trombos arteriais e venosos em mulheres, o que iria lhe impossibilitar de desenvolver uma gravidez saudável. Referiu que seria usuária do plano de saúde da demandada com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia sob o nº 0 029 170000800540 9 e estaria regularizada com suas obrigações contratuais. Mencionou que, no final do ano de 2023, engravidou e estaria gestante de 18 (dezoito) semanas de uma gravidez de alto risco. Narrou que teria sido orientada por seu médico especialista a utilizar em toda a gestação e puerpério, até 6 semanas pós-parto, o medicamento Enoxaparina Sódica 80mg, diurno - Enoxaparina Sódica 40mg, noturno - totalizando 120mg de Enoxaparina Sódica por dia, devido o comprometimento da saúde materno-fetal, doença hipertensiva (pré-eclâmpsia e eclâmpsia), insuficiência placentária, descolamento prematuro de placenta e alto risco de morte, tanto materna quanto do bebê, além de restrição de crescimento fetal e abortamento em caso de não uso das referidas injeções. Aduziu que o tratamento teria um alto custo, sendo em média por mês, custaria o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para ambas as seringas. Asseverou que não há capacidade financeira de custear todo o tratamento, considerando todo o tempo de gestação mais o tempo do pós-parto, o que perdura quase um ano e custará, no mínimo, a importância de R$ 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta reais). Afirmou que realizou o pedido administrativamente para a aquisição do medicamento de acordo com a prescrição médica, o qual restou negado, sob a justificativa de que não teria cobertura obrigatória para o medicamento em uso ambulatorial. Dissertou sobre a abusividade da conduta da demandada. Teceu considerações acerca do direito que entendia possuir. Discorreu sobre a ocorrência de danos morais e materiais. Requereu em tutela de urgência, que fosse determinado a parte demandada o fornecimento da medicação em que necessita, nas quantidades que lhe fizessem necessárias, sob pena de bloqueio judicial. Postulou a procedência dos pedidos, a fim de que a ré fosse condenada ao ressarcimento da importância de R$ 4.845,23, diante da compra do medicamente custeado pela parte aurora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a 20 salários mínimos. Pediu a inversão do ônus da prova. Pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Juntou procuração e documentos.

Foi deferida a gratuidade judiciária em favor da parte autora e a tutela de urgência.

A requerida informou o cumprimento da ordem judicial.

Citada, a parte ré apresentou contestação. Sustentou que a parte autora é beneficiária de plano privado de assistência à saúde oriundo de contrato firmado pela pessoa jurídica Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, firmado em 01.01.2012, tratando-se, assim, de plano "regulamentado", e dessa forma, sujeito às normas da LPS, consoante caput do art. 35 da referida lei, e às normas regulamentares da ANS (art. 1º, § 1º), razão pela qual a aplicação do medicamento vinculado, tem a cobertura assistencial e não é devida pelo fato de estar-se diante de medicamento não antineoplásico de uso domiciliar e não hospitalar, conforme o disposto no art. 10, inciso VI, da LPS. Referiu que o medicamento de uso domiciliar ou aplicados em caráter ambulatorial não são de sua cobertura obrigatória, exceto aqueles para tratamento de câncer. Discorreu acerca do direito que entendia possuir. Teceu acerca do pedido indenizatório por danos materiais e o adicionamento na nota fiscal de outros medicamentos distintos do objeto do feito. Destacou sobre a ausência de ilícito e configuração de exercício regular de direito para a pretensão indenizatória por danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos. Acostou documentos.

A parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento na decisão que deferiu a medida liminar, ao que foi dado provimento.

Houve réplica.

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas, as quais informaram que não teriam mais provas a produzir.

É O RELATÓRIO

PASSO A DECIDIR.

É caso de julgamento antecipado do pedido, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, haja vista que não se mostra necessária a produção de outras provas.

Pretende, a parte autora, em síntese, que seja determinado a parte ré que cumpra com sua obrigação de fazer e autorize o fornecimento do medicamento de que necessita, assim como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ab initio, ressalta-se que se está diante de uma típica relação de consumo entre as partes, o que impõe um tratamento diferenciado à lide deduzida em juízo, especificamente em relação ao ônus probante da matéria ventilada. Os litigantes encaixam-se com perfeição nos conceitos de fornecedor (artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC) e consumidor (artigo 2º do mesmo diploma). Dessa forma, mostra-se inequívoca a relação consumerista no caso em apreço.

A legislação consumerista, em seu CDC, estatui normas de ordem pública e de interesse social. Essas normas são elencadas como direitos fundamentais, com mandamento expresso (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal). Para dar efetividade a esses direitos, sobreveio o CDC, em evidente publicização do direito privado que visa a assegurar as normas protetivas constitucionais no âmbito das relações privadas, revelada como a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Convém referir que as normas do CDC conferem uma série de prerrogativas ao consumidor objetivando equilibrar a relação de consumo, porque desigual na origem diante da vulnerabilidade do consumidor.

De mais a mais, mesmo que operada a inversão do ônus probatório, a parte demandante não fica isenta de trazer um mínimo de elementos comprobatórios do seu direito, ou seja, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. COMÉRCIO DE DADOS PESSOAIS. SPC MERCADO. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO.* ***Nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil (CDC), à parte autora incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, nada obstante a possibilidade de inversão do ônus probatório em demandas que versam sobre relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, compete à parte demandante realizar, ainda que minimamente, prova dos fatos alegados.*** *No caso dos autos, entretanto, a autora não logrou êxito em comprovar, mesmo de forma mínima, a divulgação ou o comércio de seus dados pessoais, por parte da requerida. Hipótese em que a peça vestibular foi redigida de forma absolutamente genérica, não havendo indício de divulgação de dados, ou mesmo tentativa de solução do problema pela via administrativa. Deste modo, a reforma da sentença de procedência é medida que se impõe. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Apelo da autora desprovido. Apelo da ré provido. Unânime." (Apelação Cível Nº 70064090244, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 15/04/2015).*

Nesse contexto, cabe anotar que é incontroversa a contração existente entre as partes relativa ao plano de saúde, bem como a negativa da ré de autorização do fornecimento do medicamento em questão à parte autora.

Ademais, a Lei n° 9.656/98 é aplicável ao contrato em questão, pois celebrado e adaptado já na sua vigência, na esteira do que decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI n° 1931, bem como a avença está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula nº 608, com o seguinte teor:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

Dessa forma, a relação jurídica existente deve ser analisada à luz dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, para que assim seja mantido o equilíbrio entre as partes, mormente em decorrência da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nesse passo, a norma constante no artigo 47 do referido diploma legal prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o disposto no artigo 51, incisos I, II, III, IV e XV, de que são nulas, de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

> *"I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;*
>
> *II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;*
>
> *III - transfiram responsabilidades a terceiros;*
>
> *IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;*
>
> *(...)*
>
> *XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;"*

Fixadas essas premissas, passa-se analisar o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, que veio acostado no evento 14, documento 2.

No caso em exame, a controvérsia gira em torno da suposta ilegalidade da demandada em negar a cobertura de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 80mg e Enoxaparina Sódica 40mg para o tratamento de que a autora necessita para manter uma gestação saudável.

Em análise ao contrato existente, observa-se que a pretensão da autora não está expressamente incluída na cobertura do seu plano, tampouco existe cobertura específica para o tratamento de que necessita.

Nesses termos:

"XV. EXCLUSÕES DE COBERTURA

Cláusula 56. Estão expressamente excluídos desse contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, os seguintes procedimentos:

(...)

VII. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde;

VIII. Fornecimento de todo e qualquer tipo de material e equipamento para tratamento domiciliar;

(...)."

Da mesma forma, aliás, prevê o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, que serviu para fundamento de reversão da decisão liminar do evento 3, *in verbis*:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

(...)

Assim, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura quanto ao fornecimento do medicamento em questão, não há que se falar em condenação da parte ré à concessão do aludido fármaco e ao ressarcimento do valor pago pela autora para aquisição desse material, pois não coberto pelo contrato pactuado entre as partes, assim como não foram observadas cláusulas contratuais nulas de pleno direito, como dispõe o artigo 51 do CDC, citado anteriormente.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA GESTANTE E PORTADORA DE TROMBOFILIA. MEDICAMENTO ENOXOPARINA. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 3) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 4) ***Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Enoxoparina 40mg", indicado para o tratamento de Trombofilia na gestação, pertence a classe dos medicamentos "Antitromboticos" e sua administração, embora injetável, é de uso domiciliar. 5) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, descabe compelir a operadora do plano de saúde à cobertura do medicamento domiciliar postulado****. Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO." (Apelação Cível, Nº 50040109120208210017, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021).*

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE/PRÓTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie (Súmula nº 608 do STJ), por se tratar de típico contrato de adesão, o que possibilita a decretação da nulidade das cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade", bem como que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigos 6º, V, 47 e 51, IV, do referido diploma. O contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes (evento 1-doc3) está sujeito às normas da Lei nº. 9.656/1998 e às normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. As operadoras dos planos de saúde não estão obrigadas ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, caso expressamente prevista tal exclusão no contrato. Lei nº 9.656/98, art. 10, IV e § 4º De acordo com o laudo médico anexado aos autos, a autora necessita de prótese para melhorar alinhamento articular, sem referir qualquer procedimento cirúrgico anteriormente realizado. ***Dessa forma, não há como se exigir da operadora do plano de saúde o fornecimento de material sem a devida cobertura contratual. Ausência de Abusividade.*** *Precedentes do STJ e TJRS. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME." (Apelação Cível, Nº 50010723320198210026, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 17-09-2020).*

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, também não merece prosperar.

Isso porque, para que haja um dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade[1] ou à dignidade da pessoa humana[2]. Não é a dor, humilhação, vergonha que ensejam essa reparação por dano extrapatrimonial, na medida em que são situações que variam em cada indivíduo e mesmo não havendo qualquer das suas manifestações em uma determinada pessoa é possível a reparação de uma violação aos direitos da personalidade ou da sua dignidade. Como essas manifestações são consequências daquelas violações, sequer precisam ser provadas e não constituem danos morais.

É necessário olhar para o fato e ver se algum dos direitos da personalidade (vida, saúde, integridade física, imagem, etc.) ou da dignidade da pessoa humana (aquele conjunto de bens mínimos que formam o ser humano) foram violados de forma a aquilatar se há ou não o dano alegado.

Deve-se atentar para a violação desses direitos e ela é que deve ficar, ao fim e ao cabo, provada no feito.

Mas na hipótese dos autos não se percebe a violação de qualquer direito da personalidade do autor, tampouco da sua dignidade.

Cumpre ressaltar que nem mesmo houve comprovação de ilicitude da conduta imputada pela parte demandante à ré, tudo não passando de experiência comum à vida em sociedade e em um Estado de Direito, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido indenizatório.

Dessa forma, não havendo lesão aos direitos da personalidade da parte autora ou a sua dignidade, não há que se falar em danos morais.

Nessa senda:

"Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98. Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos planos não regulamentados que impede a extensão da cobertura prevista para o plano de referência, instituído pela referida norma, aos planos anteriores. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10 § 2º e 35-E da Lei 9.656/98 que estendiam sua aplicação aos planos antigos. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931. Tratando-se de contrato não regulamentado devem ser estritamente observadas as previsões contratuais a respeito das coberturas previstas e expressamente excluídas. (...). ***Dano moral. Não caracterização. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo sua interpretação contratual. Danos morais não comprovados.*** *Apelo da autora não provido. Apelo da ré parcialmente provido. Por maioria." (Apelação Cível Nº 70078057593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 19/10/2018).*

Nesses termos, a total improcedência dos pedidos é corolário lógico.

Isso posto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **LUANA PAOLA BELLO GREGORY** em face da **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.**, o que faço com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios devidos ao procurador da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atualizado atribuído à causa, forte no artigo 85, §2º, do Diploma Processual Civil, levando em conta o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a natureza da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade do ônus sucumbencial, pois o autor litiga sob o abrigo da gratuidade judiciária, em conformidade com o artigo 98, §3º, do mesmo código.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Interposta(s) apelação(ões), observe-se o contido no artigo 567, XXI[3] e XXII[4], da CNJ-CGJ/TJRS.

Ausente a interposição de recurso voluntário e/ou com o trânsito em julgado sem modificações, arquive-se.

Diligências legais.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO DEZORZI, Juiz de Direito**, em 3/6/2024, às 9:11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10057109636v18** e o código CRC **2d007926**.

1. Nessa perspectiva: LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direito da personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro: Padma, v. 2, n. 6, p. 79-98, abr./jun. 2001. ↩
2. MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. ↩
3. XXI – Juntada a apelação, cumprir as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1010 do CPC, vista ao ministério público, quando for o caso e enviar os autos ao tribunal, observando o disposto no art. 559 desta Consolidação. Se a apelação se referir ao indeferimento da petição inicial, os autos serão conclusos ao juiz para juízo de retratação (art.331 do CPC). ↩
4. XXII - Retornando os autos da instância superior, remeter os autos à contadoria, para cálculo das custas pendentes. Após, intimar as partes que não sejam beneficiárias da gratuidade judiciária para pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa. ↩